

1501289-03.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... militares imputaram-lhe o crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas não eram de sua propriedade. É usuário de crack e de cocaína. Não é traficante (fls. 183).

No entanto, as provas produzidas nos autos demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501289-03.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501289-03.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097808/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 17260245 - DEL.POL.GUARUJA, 1937/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2097808 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Douglas Ferreira de Souza, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de

abril de 2021, por volta das 09:00 horas, na Avenida Presidente Vargas, 1150, Parque Estuário, nesta cidade e comarca de Guarujá, trazia consigo e ocultava, para a entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 90 (noventa) pedras de crack, derivado da cocaína, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, e 74 (setenta e quatro) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, o auto de constatação preliminar de fls. 10/11, e as fotografias de fls. 21/24, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 71/73).

O réu foi notificado (fls. 79) e apresentou defesa prévia (fls. 86/104), que não comportou acolhimento e a denúncia foi recebida (fls. 111/113).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas seis testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 183). Encerrada a instrução, pelo representante do Ministério Público nada foi requerido, e pela defesa foi requerida a instauração de incidente de dependência toxicológica, o que foi deferido pelo juízo, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 181/182).

O laudo pericial encontra-se encartado às fls. 252/259, e a conclusão médico-legal psiquiátrica foi no sentido de que o réu é imputável para o delito descrito na denúncia.

A representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, entendendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 286/293).

Nos memoriais, a defesa do réu requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a observância do disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06., para a fixação da pena (fls. 294/299).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, pelo auto de constatação preliminar de fls. 10/11, pelas fotografias de fls. 21/24, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 71/73, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Relatou que na data dos fatos pegou R\$ 10,00 (dez reais) com sua genitora e foi comprar duas pedras de crack, pois é usuário. Encontrava-se na companhia de sua esposa, fumando as pedras de crack, quando os policiais militares chegaram ao local dos fatos e os traficantes correram. O interrogando permaneceu no local e foi abordado pela Polícia, que exigiu que o interrogando declinasse os nomes dos traficantes, ou a imputação do crime de tráfico de drogas recairia sobre ele. Declinar nomes é proibido na comunidade, porque prevalece o tribunal do crime no local dos fatos, por tal motivo o acusado nada falou. Além do crack que o interrogando estava consumindo, a Polícia encontrou mais drogas em um buraco próximo do local da abordagem, que eram do "Michel Neguim", que correu. Os policiais chegaram a alcançar o "Miguel Neguim", mas soltaram, porque não encontraram nada com ele. Com o interrogando só encontraram as duas pedras de crack, mas como ele não quis declinar os nomes dos traficantes, os policiais militares imputaram-lhe o crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas não eram de sua propriedade. É usuário de crack e de cocaína. Não é traficante (fls. 183).

No entanto, as provas produzidas nos autos demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Nelson Caetano da Silva, em juízo, relatou que na data dos fatos

se encontrava em patrulhamento de rotina, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando a equipe avistou o acusado, acompanhado de uma moça, e deliberou pela abordagem, porque o acusado demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial. Não havia outras pessoas ao lado do acusado e da acompanhante dele. Com o acusado foi encontrada uma porção de crack, nas vestes dele, e nas proximidades do local em que o acusado se encontrava foi localizada uma sacola com maconha e cocaína. Com a companheira do acusado nada foi encontrado. O depoente não se recorda se o acusado apresentou alguma versão dos fatos aos policiais. O depoente não conhecia o acusado nem a companheira dele (fls. 183).

No mesmo sentido, o depoimento judicial do policial militar Leandro dos Santos do Nascimento. Relatou a testemunha que na data dos fatos se encontrava em diligência de rotina junto com o policial militar Nelson Caetano e a equipe avistou o réu e sua companheira em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O depoente e seu colega decidiram fazer a abordagem do casal e na revista pessoal encontraram porção de drogas nas vestes do acusado. No meio-fio, nas proximidades do local de abordagem, cerca de um metro de distância, foi localizada uma sacola com quantidade considerável de drogas e três tipos diferentes de entorpecentes. Com a companheira do acusado nada foi encontrado. O depoente não conhecia o acusado nem a companheira dele. No momento da abordagem, não havia pessoas ao lado do acusado e de sua companheira. O depoente não se recorda da justificativa apresentada pelo réu para se encontrar no local dos fatos, e não se recorda se o réu tinha em sua posse algum valor em espécie. O depoente não se recorda se foi ele quem encontrou as drogas no meio-fio ou se foi seu colega Nelson Caetano (fls. 183).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição. A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

A testemunha Karina Correia de Oliveira Cabral, em juízo, relatou que o acusado, seu esposo, estava sumido. Na data dos fatos, ele pegou dinheiro com a genitora dele e foi comprar drogas. A vizinha da depoente contou-lhe que seu esposo estava em cima da ponte, que dá acesso à favela da Madalena, onde residem, e a depoente foi buscá-lo. Teve início, então, uma discussão entre o casal. A depoente queria que o acusado não comprasse droga e que fosse para a residência familiar, pois quando seu esposo usa droga arruma confusão na rua e briga em casa. No momento da discussão, os policiais militares chegaram ao local e fizeram a abordagem. Na ponte, também havia mais quatro indivíduos, além do casal - mas um deles correu - e os outros três também foram abordados e revistados. Na revista pessoal, com o acusado foi encontrada a droga que ele foi comprar. E com a depoente nada foi encontrado pela policial que a revistou. Um dos policiais se afastou um pouco e encontrou no meio-fio, num buraco lá do degrau da ponte, uma sacola com drogas, e falou que era do acusado. A depoente afirmou que ele é usuário. A família já gastou em clínicas de recuperação e não teve jeito. O acusado às vezes briga, deixa a depoente sozinha em casa e desaparece, mas não é traficante, é usuário. A depoente também é usuária de droga, mas faz uso somente de cocaína e seu esposo usa tudo que conseguir. Além do acusado e da depoente, mais três indivíduos também foram conduzidos à Delegacia de Polícia, os quais foram soltos, porque nada de ilícito foi com eles encontrado. A distância entre o local em que o acusado se encontrava e o local em que a sacola com drogas em seu interior foi localizada é superior a 30

metros. A depoente não pensou em convidar a vizinha, que lhe contou que o acusado estava na ponte, para testemunhar em juízo, em favor do acusado (fls. 183). O depoimento da esposa do réu deve ser analisado com cautela diante da evidente e natural intenção de afastar a conduta ilícita imputada ao réu. E seu depoimento não foi capaz de afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares, pois isolado nos autos.

Tem-se que diante do contexto em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do acusado, diante da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, incompatíveis com o uso, da forma de acondicionamento dos entorpecentes e de todas as circunstâncias que culminaram com a abordagem e a prisão do réu, restou comprovada a conduta típica narrada na inicial acusatória.

E os depoimentos das testemunhas de defesa também não foram capazes de afastar a conduta típica praticada pelo réu.

Leandro Batista Gomes, em juízo, relatou que não presenciou os fatos tratados. Conhece o acusado desde criança, e sabe que ele dá muito trabalho para a mãe dele, pois é usuário de drogas pesadas e também é alcoólatra. O acusado trabalha recolhendo material de reciclagem. Em razão de sua condição de usuário de drogas e de alcoólatra, o acusado já esteve envolvido em muitas confusões na rua, inclusive sendo vítima de agressões físicas e ameaças de morte (fls. 183).

Robson Willian Batista Cruz, primo do acusado, em seu depoimento judicial, relatou que o acusado tem problemas sérios com drogas, é usuário. O depoente não presenciou os fatos. Na noite anterior aos fatos, o acusado estava com sua esposa em um bar bebendo e o depoente o cumprimentou e até sugeriu em tom fraternal que ele fosse para casa, que ali não era um local apropriado para ficar. No dia seguinte o depoente soube da prisão do acusado. Acredita que o réu seja só usuário, porque o problema do acusado com drogas é tão grande que se dessem drogas para ele vender, o depoente acredita que ele consumiria tudo. A esposa do acusado também é usuária de drogas. O depoente desconhece se o acusado trabalha recolhendo material de reciclagem. Quando o acusado precisa de dinheiro, recorre à genitora dele, tia do depoente. O acusado já foi internado algumas vezes em clínica de recuperação de dependentes químicos (fls. 183).

Emelin Felizardo, amiga da família do acusado, em juízo, relatou que na data dos fatos estava na ponte conversando com uma amiga e lá também estavam outras pessoas, além do acusado e da esposa dele, e o casal estava discutindo. Os policiais militares chegaram e fizeram a abordagem de rotina, chamando o acusado para um canto. Após a revista pessoal, encontraram com o acusado droga para uso próprio. A droga encontrada no buraco do meio-fio não era de Douglas, e a depoente não sabe de quem era. As demais pessoas que estavam na ponte correram quando perceberam a aproximação da viatura policial, somente Douglas e Karina não correram e foram abordados e revistados. A depoente não viu se o acusado portava alguma bolsa ou alguma pochete. O acusado é usuário de droga, e dá muito trabalho para a mãe dele. A esposa do acusado também é usuária de droga. O acusado trabalha recolhendo material reciclável. Antes da chegada dos policiais militares, a depoente presenciou indivíduos vendendo drogas no local dos fatos, os quais correram, quando a Polícia chegou. Não se lembra com exatidão se somente o acusado e a esposa dele foram levados para a Delegacia de Polícia, porque ficou tumultuado o local, mas afirma que os indivíduos que também estavam na ponte, antes da chegada da Polícia, correram (fls. 183).

Pois bem, as testemunhas de defesa Leandro Batista e Robson não presenciaram os fatos, somente discorreram acerca da conduta social do acusado.

Por sua vez, a testemunha Emelin afirmou que se encontrava na ponte conversando com uma amiga e também havia outras pessoas nessa ponte, local dos fatos. Quando as pessoas perceberam a chegada da viatura policial, todas correram, só ficaram o acusado e Karina, e por tal motivo somente os dois foram abordados e revistados.

Tal versão entra em conflito com o depoimento dos policiais militares e com o depoimento de Karina. Os policiais militares relataram que não havia mais pessoas na ponte, somente o acusado e sua companheira e foram abordados, revistados, detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia. E Karina relatou que havia mais quatro

pessoas, além dela e do acusado, mas somente uma pessoa correu. As demais também foram abordadas, revistadas, detidas e conduzidas à Delegacia de Polícia, mas colocadas em liberdade na sequência, porque com elas nada de ilícito foi encontrado.

Logo, os depoimentos das testemunhas de defesa não foram capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos policiais, que devem prevalecer.

Assim, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o acusado trazia consigo e ocultava os entorpecentes, e os entorpecentes eram destinados para a entrega a consumo de terceiros, ante a conduta do acusado narrada pelos policiais que fizeram a abordagem e a prisão em flagrante do acusado.

Destaque-se que o artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias entorpecentes para sustentarem o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

A propósito:

"(...) Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo, infelizmente, comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de financiar seu vício (...)." (TJSP, Apelação nº 0000136-06.2016.8.26.0626, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Damião Cogan, julgado em 10/05/2019)

Nesse sentido, ainda:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (TJSP - HC 42.229-3 -Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498)

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, uma vez evidenciado que o entorpecente apreendido com o réu era destinado para o consumo de terceiros. Ressalte-se que no laudo pericial encartado às fls. 252/259 a conclusão médico-legal psiquiátrica foi no sentido de que o réu é imputável para o delito descrito na denúncia.

Assim, uma vez comprovada a materialidade, a autoria, e definida a conduta do acusado, impõe-se a procedência da ação penal.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 26, Processo nº 0002337-33.2007.8.26.0093), e ante a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, elevo a pena-base em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência do réu (fls. 27, Processo nº 0002491-34.2016.8.26.0223) elevo a pena em 1/6, perfazendo a reprimenda o montante de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isto porque, para a sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, verifica-se que o réu foi detido na posse de variadas drogas e já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas (fls. 28, Processo nº 0005238-68.2010.8.26.0642), demonstrando, desta forma, que se dedica com habitualidade à atividade criminosa reiterada, destinada à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, circunstância impeditiva da aplicação do redutor. As circunstâncias dos fatos

demonstram que o réu fazia do tráfico de drogas meio de vida.

Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado, por entender ser o regime adequado à conduta do réu, que demonstrou se dedicar a atividade criminosa.

Ressalte-se que, considerando a pena definitiva aplicada, bem como a gravidade do delito, não são cabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando que o réu é reincidente, não é possível neste momento apreciar se faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na Lei de Execução Penal. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Douglas Ferreira de Souza para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

O acusado não poderá apelar em liberdade. De fato, preso em flagrante, assim permaneceu durante toda a instrução e, agora, com a presente condenação, mais razão ainda para permanecer custodiado. Trata-se de crime grave, equiparado a hediondo, e se o réu aguardar em liberdade o direito de recorrer poderá não ser mais encontrado para a aplicação desta decisão, tornando-a inócua. Ainda, em liberdade, o acusado poderá reiterar a prática de condutas ilícitas.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Nos termos da Lei nº 11.343/2006, após o trânsito em julgado oficie-se à autoridade policial com determinação de destruição da porção de droga reservada para eventual contraprova.

No que tange às custas processuais, verifica-se à fl. 113 que foi deferido o benefício da gratuidade da Justiça ao réu.

P. I. C.

Guaruja, 31 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA